

1502311-74.2022.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... DJe 15/09/2015). APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ALÉM DO MÍNIMO LEGAL PELOS MOTIVOS DO CRIME. ROUBO COMETIDO PARA COMPRAR DROGAS. POSSIBILIDADE. MAJORANTES NA FRAÇÃO DE 2/5 FUNDAMENTADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. POSSIBILIDADE. Recurso improvido. 1. É possível a valoração negativa dos motivos do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Rua Doutor Lycio Brandao de Camargo, 50, Vila Clementina - CEP 19802-300, Fone:

(18)3322-6011, Assis-SP - E-mail: assis3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1502311-74.2022.8.26.0047

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266517/2022 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 27748520 -

DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2266517 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS MARQUES RIBEIRO

Vítima:

ESCOLA ESTADUAL LUCAS TOMAS MENCK e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

10/11/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 10 de novembro de 2022, às 14h, na sala de audiências virtual da 3ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Assis, Estado de São Paulo, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor ARNALDO LUIZ ZASSO VALDERRAMA, Meritíssimo Juiz de Direito, acompanhado do Escrevente ao final nomeado, foi aberta a presente audiência nos autos da ação e entre as partes em epígrafe, realizada na modalidade de teleconferência, através de ferramenta disponível no Microsoft Teams. Apregoadas as partes, participaram o Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Fernandes Fraga, Promotor de Justiça, o réu Marcos Marques Ribeiro, apresentado para a teleconferência pelo Centro de Detenção Provisória de Caiuá, nas dependências daquela unidade, sua advogada, Dra. Sirlene Martins da Luz, OAB/SP309.916, a vítima José Carlos de Goês Júnior, e a testemunha Ygor Renox Bauer

Costa. Ausente a testemunha Edson Luiz de Souza Júnior. Iniciados os trabalhos, procedeu-se ao interrogatório do acusado, a oitiva das testemunhas e apresentação de alegações finais orais pelas partes. Os depoimentos foram capturados pelo sistema audiovisual, na modalidade de teleconferência, nos termos Comunicado CG Nº 284/2020, da Corregedoria Geral da Justiça, cujos arquivos são acessíveis por download, em link a ser disponibilizado, e gravada no CD encartado. Inclusive, feita a advertência que a gravação destina-se, exclusivamente, aos processos judiciais, desautorizada qualquer divulgação ou transmissão de sua imagem por qualquer meio, sob pena de apuração de responsabilidade civil e criminal. O Ministério Público e o Advogado do acusado desistiram da oitiva da testemunha Edson Luiz de Souza Júnior, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Vistos. O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra Marcos Marques Ribeiro, qualificados nos autos, como incursos no art. 155, §4º, I e II, c.c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. Narrou que no dia 29 de setembro de 2022, por volta das 09h25min, na rua General Osório, nº465, Vila Santa Cecília, nesta cidade e Comarca, o acusado tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada, 07Kg de fio de cobre, avaliados em R\$ 140,00, de propriedade da EMEI Lucas Tomas Menck, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo apurado, Marcos dirigiu-se à escola, escalou até o telhado, removeu telhas e entrou pelo forro da escola; com um alicate, cortou alguns metros de fio de cobre e os enrolou em um cobertor para a realização do transporte; um vizinho da escola acionou a Polícia Militar e os agentes públicos chegaram ao local enquanto o denunciado, ainda dentro do estabelecimento, havia deixado os fios na laje para o posterior transporte e se escondeu atrás de uma bancada, local em que foi encontrado e preso em flagrante delito. A denúncia foi recebida em 05/10/2022 (fls.131/132). Citado, o réu apresentou defesa preliminar (fls.159/160). Nesta data foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu. Em alegações finais orais o douto membro do Ministério Público pleiteou a condenação do réu, sob os argumentos de que a prova oral e confissão demonstrou a prática de furto cometido mediante escalada; não ficou caracterizado o rompimento de obstáculo; deve ser aumentada a pena pelos maus antecedentes, reincidência, ser atenuada a pena pela confissão, tentativa e ser fixado o regime inicial fechado e não substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. A douda Defesa pleiteou a absolvição do réu pela aplicação do princípio da insignificância ou, em caso de condenação, o reconhecimento da confissão e da tentativa; deve ser dispensada a multa pela hipossuficiência do réu. É o relatório. Fundamento e decido. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação é procedente. A materialidade do delito de furto tentado foi comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fl.01), boletim de ocorrência (fls.45/47) e auto de exibição e apreensão (fl.50). A autoria do delito também é certa e atribuída apenas ao réu, conforme se extrai da prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Em seu interrogatório Marcos confessou o crime. Afirmou que não achava serviço por causa do crack, viu um rapaz com saco nas costas, pediu a ele para lhe dar um quilo. Relatou que falou que era para comprar comida, mas na verdade era para fumar crack. Mencionou que a pessoa falou que tinha deixado um kg no forro e deu um alicate. Declarou que subiu no telhado e já estava aberto, lá tinha os fios, tinha mais uns pedaços sobrando sem arrancar e cortou. Disse que pretendia comprar comida, crack e cigarro. Falou que ao sair resolveu ir para baixo e deixou os fios e alicates, tentou se esconder. Informou que já usou crack por quinze anos. Narrou que entrou por um murinho, o rapaz falou para subir no telhado. Ressaltou que já foi condenado por furto e está arrependido, não tinha emprego. A testemunha José Carlos afirmou que dava aula quando viu a polícia entrando no prédio e eles perguntaram se tinha chave da escola e entregou a ele. Relatou que saiu ver o que acontecia e eles já tinham pegado esse senhor, que estava fora da calçada. Mencionou que só o viu quando estava fora da escola, não o viu entrar. Declarou que lhe apresentaram um rolo de fio que ele tinha arrancado. A testemunha Ygor afirmou que estava de serviço com sua equipe, receberam solicitação 190 e o cidadão informava ter visto indivíduo no telhado ao prédio ao lado da escola Lucas Tomas Menck, tirou telhas e adentrou. Relatou que entrou no local por

onde Marcos havia ingressado, ele desceu e se escondeu. Mencionou ter encontrado rolo de fio com 7kg e um alicate. Declarou que no solo a equipe achou Marcos escondido atrás de um balcão antigo. Disse que o réu admitiu o crime e falou que buscava os fios mediante indicação de um amigo que já havia retirado outro rolo de fios e venderia por R\$ 20 o quilo. Pois bem. Queda-se remansosa a inexistência de qualquer ato de disposição por parte da vítima que legitimasse a tentativa de posse dos fios de cobre por Marcos. A inexistência de autorização do proprietário torna certo que ele estava a possuir “coisa alheia móvel”, elemento essencial do tipo penal e, por isso, detinha pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta. Segundo as testemunhas, a polícia foi acionada porque um vizinho viu uma pessoa no telhado da escola, os policiais entraram pelo telhado e lá separou uns fios de cobre para furtar, mas foi impedido por circunstâncias alheias à sua vontade. A confissão do réu foi corroborada pelo conjunto probatório. A qualificadora de escalada foi comprovada nos autos, eis que o réu escalou o muro da escola e ingressou pelo telhado. Concorro com o Ministério Público ao pedir o afastamento da qualificadora do arrombamento, eis que segundo a jurisprudência a mera remoção de telhas sem qualquer esforço especial constitui mero desdobramento da qualificadora relativa à escalada e seria bis in idem a dupla qualificação dessa circunstância. No caso vertente deve ser aplicado o tipo penal da tentativa, formado com a aplicação do art. 14, inciso II, do Código Penal. O requerido deu início à execução do delito, mas por circunstâncias alheias à vontade dele o crime não se consumou, não chegando a res furtiva a sair da esfera de vigilância do legítimo proprietário. A pretensão defensiva de que teria ocorrido crime de bagatela, pela aplicação do princípio da insignificância, não merece ser acolhida. Tal princípio, idealizado por Claus Roxin, preconiza que a tipicidade penal demanda uma ofensa grave aos bens jurídicos tutelados, sob pena de não caracterização do injusto típico. Assim, em certas situações é possível afastar a tipicidade penal, pois o bem não foi lesado. Entretanto o crime, como fato social que é, deve ser apreciado em sua inteireza, devendo a aplicação do princípio da bagatela nortear-se não só pela afetação do bem jurídico ou desvalor do resultado, mas também pelo desvalor da ação, circunstâncias do crime, repercussão na esfera da vítima e antecedentes do acusado. No caso concreto o valor do objeto furtado supera um pouco 10% do salário-mínimo, patamar aceito pela jurisprudência para caracterizar a bagatela. Ademais, embora inexista repercussão na esfera patrimonial da vítima, não há como dizer que a ação delitiva foi de mínima ofensividade, sem periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, seguindo a linha de posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o réu possui seis condenações anteriores, é multireincidente e ostenta péssimos antecedentes, o que potencializa a lesividade da conduta. Em que pesem respeitáveis entendimentos jurisprudenciais de que é irrelevante a vida pregressa do acusado, a aplicação do princípio neste caso concreto apenas serviria de estímulo a pequenos furtos. Além disso, existe forte jurisprudência no sentido da necessidade de se considerar a personalidade e a conduta social do réu para aplicação do princípio da insignificância, conforme se observa nos julgados: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II Pedido de aplicação do princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Com efeito, “a Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável” (RHC n. 118.548/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 13/12/2019). III – Na hipótese em foco, observa-se não ser recomendável a aplicação do princípio da insignificância. Isso porque o paciente ostenta diversos maus antecedentes e, ainda, é reincidente. Ademais, o ínfimo valor da res furtiva, diante das referidas circunstâncias não tem o condão de, por si só, atrair a incidência do princípio bagatelar. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.553.855/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 26/11/2019; AgRg no HC n. 516.674/MG, Quinta Turma, Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado Do TJ/

PE), DJe de 29/10/2019; e HC n. 540.456/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 09/12/2019. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 695.458/MG, Rel. Ministro Jesuino Rissato (Des. do TJDF), Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021). (...) para o reconhecimento do aludido corolário (princípio da insignificância) não se deve considerar tão-somente a lesividade mínima da conduta do agente, sendo necessário apreciar outras circunstâncias de cunho subjetivo, especialmente àquelas relacionadas à vida pregressa e ao comportamento social do sujeito ativo, não sendo possível absolvê-lo da imputação descrita na inicial acusatória, se é reincidente, portador de maus antecedentes ou, como na espécie ocorre, reiteradamente pratica o questionado ilícito como ocupação (STJ, HC 33.655-RS, rel. Min. Laurita Vaz, j. 01.06.04, destaquei). Apelação Criminal - Furto e estelionato. - Preliminar de nulidade não acolhida - Inexistência de cerceamento do direito de defesa (...) Princípio da insignificância: Identificação que não depende exclusivamente do valor econômico da res furtivae - A natureza dos crimes e a personalidade do acusado (que possui anteriores condenações por crimes patrimoniais) obstam a aplicação do princípio da insignificância - Caso, ademais, que não permite atribuir valor ínfimo aos bens furtados. (...) (TJSP, Apelação nº 990081790084, Órgão: 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator(a): José Raul Gavião de Almeida, j.: 28/01/2010, destaquei). FURTO - ABSOLVIÇÃO - DOLO - AUTORIA COMPROVADA. (...) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E FURTO PRIVILEGIADO - APLICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE, EM FACE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU. Obstada está a pretensão de afastamento da pena pelo furto de bagatela ou pela aplicação do privilégio, previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, se as condições pessoais do réu não o recomendam, mormente sendo portador de péssimos antecedentes, além de multirreincidente específico, em face da fusão entre o princípio da insignificância e da irrelevância penal para fins de aplicação. (...) (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0116.08.016392-0/001(1), 1ª Câmara Criminal, Rel. Judimar Biber. j. 28.04.2009, Publ. 27.05.2009, destaquei). Tal entendimento foi corroborado no julgamento do HC 102.088, em 06.04.2010, pela 1ª Turma do E. Supremo Tribunal Federal, cuja relatora Min. Carmen Lúcia asseverou que: "a relevância jurídica não é o valor. E neste caso a justificativa foi sempre que há uma reiteração de comportamento nos mesmos moldes, na mesma condição". Embora ainda haja uma parcela da jurisprudência leniente com a criminalidade, a experiência internacional mostra que aceitar de maneira irrestrita a insignificância acarreta um incremento significativo da criminalidade em prejuízo de toda a sociedade. Basta ver o que está acontecendo na cidade americana de San Francisco. De acordo com matéria do periódico Gazeta do Povo, "representantes da rede Walgreens disseram que os roubos em suas lojas de San Francisco eram quatro vezes maiores do que a média nacional da rede e que ela havia fechado 17 lojas, em grande parte porque a escala de furtos tornava os negócios insustentáveis (...) a rede de farmácias CVS disse a Fuller que San Francisco havia se tornado "um dos epicentros do crime organizado no varejo" e que a rede reduziu a fiscalização dos guardas de segurança contra furtos em lojas porque isso se tornou muito perigoso (...) Em 2014, um referendo eleitoral determinou que furtos de bens inferiores a US\$950 fossem considerados contravenção, e não crime. Nos anos seguintes, as acusações de furto no varejo diminuíram significativamente. "Furtar tornou-se parte da cultura", comentou o político local Ahsha Safaí sobre o furto. "As pessoas dizem: 'Oh, bem, isso simplesmente acontece. [Ladrões] estão obviamente escolhendo os locais com base nas consequências. Como não há consequências para suas ações, você convida ao comportamento. De novo e de novo." (<https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/sao-francisco-enfrenta-onda-de-furtos-que-esta-levando-lojas-a-falencia/>, acesso em 18/07/2022). Este resultado ocorrido em San Francisco demonstra, sem sombra de dúvidas, que o economista norte-americano Gary Becker estava certo ao concluir que o ato criminoso decorreria de uma avaliação racional em torno dos benefícios e custos advindos da conduta delitiva. Segundo a teoria do ganhador do Prêmio Nobel de Economia, o cometimento do crime dependeria de três fatores: o tamanho da recompensa proporcionada pelo cometimento do crime, a probabilidade de ser preso e condenado e o rigor da pena a cumprir. Ou seja, quanto maior o tamanho da recompensa potencial em delinquir maiores serão os índices de criminalidade. Quanto maiores as probabilidades de prisão e de

apenamento rigoroso, menores serão os índices de criminalidade (Crime and punishment: an economic approach, Journal of Political Economy, 1968, p.169-217). Voltando para o caso concreto, passar a mão na cabeça do réu como se não tivesse feito nada de ilícito jamais irá contribuir para a sua ressocialização nem servirá como estímulo para se tornar um cidadão de bem. Pelo contrário, apenas servirá para que ele e outros indivíduos se sintam motivados a ganhar a vida praticando pequenos delitos. Por fim, aqui se trata de um furto qualificado pela escalada, o que de acordo com parte da jurisprudência também justifica o afastamento dessa tese. Ultimada a instrução do feito, tenho que as provas se revelam impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória. Havendo prova suficiente a comprovar a autoria e materialidade delitiva, presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu nas penas dos crimes de furto tentado é medida que se impõe. Passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos arts. 59 e 60 do Código Penal, eis que em benefício do réu não milita quaisquer justificativas ou dirimentes: A culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade da conduta do réu, é normal para a espécie. O réu é multireincidente (3) e possui outras três condenações transitadas em julgado e cujas penas foram extintas há mais de cinco anos. Ressalto que o Supremo Tribunal Federal decidiu que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como Maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal. De acordo com o entendimento, o instituto dos Maus antecedentes não é utilizado para a formação da culpa, mas para subsidiar a discricionariedade do julgador na fase de dosimetria da pena, quando já houve a condenação. A decisão se deu por maioria de votos no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 593818, com repercussão geral reconhecida (Tema 150), na sessão virtual encerrada em 17/8/2020. No mesmo sentido é o entendimento do STJ: "O conceito de Maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como Maus antecedentes" HC n. 337.068/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/6/2016. Ainda, menciono: HC n. 413.693/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/10/2017" (STJ, AgRg no HC 455.563/MS, 5ª Turma do STJ, Rel. Félix Fischer, j. 18/10/2018). Reconheço que os motivos foram mais graves porque a destinação da subtração foi a aquisição de drogas. O uso repetido de entorpecente revela má conduta, mau hábito, que retira o cidadão de relações salutaras e o coloca em contado frequente com o mundo do crime, em prejuízo da sociedade. É mais grave que o crime praticado pelo criminoso com o intuito de sustentar família. A jurisprudência admite a possibilidade de considerar tal circunstância para agravar a pena, seja como má conduta social, seja pelo motivo reprovável do crime. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE RECEPÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CITAÇÃO DO CONCEITO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. CONDUTA SOCIAL. PREJUÍZO ÀS RELAÇÕES FAMILIARES. POSSIBILIDADE. MOTIVOS. OBTENÇÃO DE DROGAS. RAZÃO NÃO INERENTE AOS DELITO PATRIMONIAIS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. O aumento da pena-base pela culpabilidade requer fundamento concreto, não se prestando a tal a mera citação do conceito de culpabilidade. 3. O conceito de conduta social tem por fim examinar a interação do agente em seu meio, ante familiares, amigos e vizinhos, razão pela qual a motivação posta, fulcrada, outrossim, no fato de que o consumo de drogas por parte do paciente vinha prejudicando também a sua família, mostra-se plenamente válida. 4. A valoração negativa dos motivos do delito em virtude do objetivo perverso de obtenção de entorpecentes, em prejuízo da propriedade e da liberdade alheias, por desbordar dos inerentes à espécie (receptação de um veículo), justificando, portanto, a exasperação da pena-base, sendo imprópria a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias nesta sede. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas do paciente a 1

ano e 10 meses de reclusão e 16 dias-multa. (STJ, HC 162.988/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 15/09/2015). APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ALÉM DO MÍNIMO LEGAL PELOS MOTIVOS DO CRIME. ROUBO COMETIDO PARA COMPRAR DROGAS. POSSIBILIDADE. MAJORANTES NA FRAÇÃO DE 2/5 FUNDAMENTADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. POSSIBILIDADE. Recurso improvido. 1. É possível a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o réu alega que praticou o roubo para comprar drogas (...) (TJES, Apelação 00156271920178080012, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j.13.03.2019, publicação 22.03.2019). As circunstâncias do crime foram inerentes ao tipo penal. As consequências não são desfavoráveis. O comportamento do ofendido não influenciou o réu a praticar a conduta. Na primeira fase, após considerar tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Na segunda fase verifico que ficou caracterizada a agravante da reincidência, prevista nos arts. 61, inc. I, e 63, ambos do Código Penal. Nesse aspecto, a doutrina estabelece que "o quantum da agravação depende do arbítrio do juiz, calcado nas circunstâncias do dado concreto e nos dados inerentes à pessoa do agente" (Damásio de Jesus, in Código Penal Anotado, 17ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p.218). No caso concreto a reincidência de Marcos é específica, visto que ele foi condenado anteriormente por furto várias vezes e persistiu na senda do mesmo crime, é multireincidente. O Supremo Tribunal Federal já admitiu a possibilidade de uma majoração da pena maior que a natural em casos como este, pois tal prática "demonstra certa profissionalização ou especialização da conduta criminoso". No final, o acórdão ficou ementado da seguinte forma: PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. (...) II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 101.918/MS, 1ª Turma do STF, Rel. Ricardo Lewandowski. j. 11.05.2010, unânime, DJe 04.06.2010). A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pelo maior aumento em razão da reincidência específica. Confira-se: "A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (STJ, HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 18/02/2014)". Costumo agravar a pena em 1/3 (um terço) em razão da reincidência específica, mas sopesando que houve a confissão espontânea é caso de agravar em apenas 1/6 (um sexto) e elevar a pena para 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Na terceira fase não há causa de aumento A diminuição relativa à tentativa (art. 14, Código Penal) deve atender ao critério do caminho já percorrido pelo agente na prática do delito (iter criminis), ou seja, quanto mais próximo da consumação do delito menor será o abatimento. Levando-se em conta que o réu já havia cortado o fio e estava mais próximo da consumação, deve a pena ser diminuída em 1/3 (um terço), atingindo o patamar final de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual no mínimo legal, em face da situação de desemprego apurada no interrogatório judicial, valor que deverá ser atualizado até o pagamento, segundo art. 49, caput, e § 2º c/c o art. 60, caput, do CP. A pena de multa está expressamente prevista no preceito secundário da norma penal contida no art. 155 do Código Penal, e por isso, não pode julgador deixar de aplicá-la, ainda

que comprovada possível hipossuficiência do réu. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita tem o condão de afastar somente a condenação ao pagamento das custas processuais. Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade fixo o regime fechado, com esteio no § 3º, do art. 33, do Código Penal, o qual determina que o regime prisional deve ser fixado com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma, pois se trata de réu reincidente específico e é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio. Nesse sentido, cite-se o julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: apelação 990090253380, órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal, rel.: Pedro Menin, data do julgamento: 04/08/2009. Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em atenção ao art. 44, II, do Código Penal, ante a reincidência específica, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, II, do CP, pelo motivo acima declinado. Por fim, foi publicada a Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal. Esta possui previsão legal no art. 42 do Código Penal, segundo o qual "computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior". Pelo art. 1º: "a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, nos termos desta lei". Já o art. 2º traz o § 2º ao art. 387 do CPP: "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Reputo a lei constitucional, por representar a vontade legítima do legislador de diminuir o tempo de espera para a progressão do regime e por competir ao legislador a tarefa de determinar o momento e juízo competente para efetuar a detração. Neste caso concreto o réu somente faria jus à progressão de regime após o cumprimento de 20% da pena, o que não ocorreu. Assim, apesar da detração ora realizada, o regime inicial de cumprimento da pena restante ainda será o fechado. Diante do exposto, com fundamento no art. 387, do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão veiculada nesta ação penal para: CONDENAR o réu Marcos Marques Ribeiro, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual no mínimo legal, como incurso no art. 155, § 4º, inciso II, c.c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal; CONDENAR o réu ao pagamento das custas judiciais, previstas no art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, por se tratar de réu pobre. Uma vez que se cuida de réu que viu o desenrolar do processo sob custódia cautelar, é reincidente específico e com maus antecedentes, tudo a indicar periculosidade, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, considerando a necessidade de garantir a ordem pública e as jurisprudências que adoto como razão de decidir, in verbis: "Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHCnº111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013). "(...) Não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ. A custódia provisória para recorrer não ofende a garantia da presunção da inocência. Incidência do verbete da Súmula n.º 09/STJ. Eventuais condições favoráveis do agente, como primariedade e bons antecedentes, não são garantidoras de direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos dos autos recomendam a custódia preventiva. (...) " (STJ, RHC 18438/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 19.12.2005, p. 446, destaquei). Recomende-se o réu no local onde está detido, encaminhando-se cópia desta sentença ao ilustre Diretor do estabelecimento prisional. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Deixo de arbitrar indenização mínima em favor da vítima porque não consta que ela sofreu

prejuízo. Transitada em julgado, determino as seguintes providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105

da Lei de Execução Penal; 4) Comunique-se à ofendida do conteúdo desta decisão, ex vi do art. 201, § 2º, do CPP; 5) Expeça-se certidão de honorários à douta Advogada nomeada; 6) Requisite-se a destruição dos objetos apreendidos; 7) Certifique-se o cálculo da pena de multa e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015, disponibilizado no D.J.E. de 27/02/2015; 8) Após, intime(m)-se o(s) réu(s), via carta de intimação com AR, a fim de que pague(m) a multa (privativa/cumulativa) em favor do FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - a ser feito no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de execução da pena pecuniária pelo Ministério Público; 8) Comprovado o pagamento da multa, certifique-se e comunique-se à VEC; 9) Se o(s) réu(s) não for(em) encontrado(s) ou não pagar(em) no prazo supra, certifique-se, extraia-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público para ajuizar ação de execução junto à VEC. Lance-se a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal", a qual atribuíra ao processo a situação "suspensão", e encaminhe-se o processo com tramitação digital, automaticamente, para a fila "Ag. Execução - Pena de Multa"; 10) Não havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para extinguir a pena e determinar a remessa dos autos ao arquivo definitivo; 11) Com a comunicação, pelo Juízo da execução, do ajuizamento da ação de execução da multa penal, anote-se no histórico de partes o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução; 12) Após, lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação" e arquivem-se os presentes autos; 13) Com a comunicação, pelo Juízo da Execução, da extinção da pena de multa, altere-se a situação do processo com o lançamento da movimentação "Cód. 22- Baixa Definitiva". Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Em seguida, o(a)(s) Defensor(a)(es) e o(s)réu(s) manifestou(aram) o desejo de recorrer contra a sentença proferida nesta data. Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos. 1. Recebo o recurso interposto pelo(a) defensor(a). Sai o(a) Defensor(a) intimado(a) para apresentação das razões no prazo de 8 (oito) dias. 2. Se não forem apresentadas razões no prazo, intime o Advogado para apresentar as razões em 24 (vinte e quatro) horas. 3. Se não fizer, comunique o fato à OAB, nomeie outro Defensor e o intime para apresentar as razões recursais no prazo legal. 4. Expeça-se a certidão de honorários parciais à douta Defesa em 70% do respectivo item do convênio firmado entre a Defensoria Pública e a OAB. 5. Após a expedição da certidão, intime-se o recorrido para apresentação de contrarrazões no prazo de 8 (oito) dias; 6. Expeça-se a guia de execução provisória e envie-se à VEC competente. 7. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para julgamento do recurso de apelação interposto pelo(s) sentenciado(s), observando-se as formalidades legais. Considerando a pena imposta, anoto que a prescrição da pretensão punitiva ocorrerá em 09 de novembro de 2026. Saem os presentes intimados. Nada mais. Lido e achado conforme. Dispensada a assinatura dos presentes, nos termos do art. 1.269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Eu, Maria Augusta Rocha Mantovani, escrevente "ad hoc", digitei.